

1500288-19.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... autos, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme exordial acusatória de fls. 131/133.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados, apresentando defesas prévias (fls. 176/177, Ana; fls. 180/219, Iago; e fl. 236, Elza). A seguir, a denúncia foi recebida, em 24/08/2021 (fls. 245/249).

Durante a instrução foram ouvidas as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500288-19.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500288-19.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069744/2021 - 02º D.P. LORENA, 16727787 - 02º D.P. LORENA, 102/21/212 - 02º D.P. LORENA, 2069744 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELZA KARLA NOGUEIRA DA SILVA e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de IAGO FELIPE EUFRAZIO EUGENIO, ELZA KARLA NOGUEIRA SILVA e ANA CAROLINE NOGUEIRA RODRIGUES MARÇAL, qualificados nos autos, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme exordial acusatória de fls. 131/133.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados, apresentando defesas prévias (fls. 176/177, Ana; fls. 180/219, Iago; e fl. 236, Elza). A seguir, a denúncia foi recebida, em 24/08/2021 (fls. 245/249).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas, sendo realizado os

interrogatórios dos réus, ao final. Na sequência, as partes apresentaram suas alegações finais por meio de memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência integral da ação penal, com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 430/434).

Por sua vez, a defesa do corréu Iago pugnou pela sua absolvição, por falta de prova da materialidade delitiva, à vista da ausência de laudo definitivo das drogas. No mérito, defendeu não existirem provas da existência do fato, ou este não constituir infração penal. Subsidiariamente, ad argumentandum, pleiteou a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, além do reconhecimento da atenuante da confissão. Em caso de condenação na forma da denúncia, requereu o reconhecimento da figura privilegiada do tipo; a substituição da pena privativa por restritivas de direito; e o apelo em liberdade (fls. 440/492).

Em sentido semelhante trilhou a defesa das corrés Ana e Elza (fls. 497/503).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, refuta-se a preliminar invocada pela defesa de Iago, diante da vinda do laudo químico-toxicológico de fls. 507/509.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade narcotraficante encontra-se comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva; como auto de prisão em flagrante (fls. 01/03 e 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), laudo de constatação provisória (fls. 35/44) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 507/509), com resultados positivos para "cocaína" e "maconha", substâncias presentes nas listas da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

De igual modo, a autoria do crime de tráfico é certa, ao menos em relação ao corréu Iago, conforme se verá mais a frente.

O investigador de polícia Maurílio Abreu Aquino contou ter sido o responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço de Iago e Ana, esclarecendo que durante a diligência apenas localizou a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Contudo, após notar a inquietação dos acusados, e a existência de um alçapão que dava acesso ao forro da residência, tratou de inspecionar o local, lá encontrando os entorpecentes e apetrechos apontados na denúncia (155 pinos de "cocaína", e outras 27 porções de "maconha", além de 339 invólucros plásticos vazios). De acordo com o depoente, a outra equipe policial responsável por dar cumprimento à ordem judicial no endereço da corré Elza também apreendeu certo volume de narcóticos, embora em menor quantidade. Asseverou que durante campanhas, realizadas anteriormente a expedição do mandado de busca e apreensão, visualizou Iago em movimentação típica do vil comércio, atendendo diversas pessoas em seu imóvel que o procuravam, fazendo o famoso gesto de "dar e receber" algo. Por fim, explicou que no limiar das investigações, a polícia acreditava que o réu chamava-se Igor, apenas desvendando sua correta qualificação após a execução da ordem judicial.

Já o policial civil César Augusto das Chagas contou ter participado das buscas na residência de Elza. Disse que na ocasião, a acusada, de imediato, tirou do interior de suas vestes íntimas, duas porções de "maconha", sendo que após ser questionada se havia mais ilícitos, silenciou-se. Segundo o depoente, dentro de uma cômoda e embaixo do colchão foi localizado dinheiro, e no interior de uma fralda descartada no cesto do lixo do banheiro, mais drogas.

Por sua vez, Elza declarou inocência durante sua autodefesa. Admitiu que, de fato, guardou em suas vestes os pinos de "cocaína" entregue aos policiais, e dispensou as drogas encontradas dentro da fralda. Disse que assim o fez, pois iria procurar seu marido, a fim de questioná-lo sobre a existência de tais ilícitos em sua casa, no exato momento da chegada dos policiais. A interroganda declarou que seu esposo é usuário de drogas, negando envolvendo com o vil comércio.

Já Iago, diferentemente de Elza, confessou parcialmente os fatos em seu interrogatório. Declarou que passou a residir no imóvel, local dos fatos, por estar vazio, após chegar à cidade, vindo de Minas Gerais. Afirmou que a corré Ana morava com sua genitora, ora acusada Elza, em frente à residência, e ficaram amigos. Negou que possuísse relacionamento com Elza, pois esta não aceitava sua condição de usuário de entorpecentes. Relatou que, no afã de angariar fundos para retornar ao seu estado natal, acabou aceitando guardar drogas para terceiros, mediante pagamento. De acordo com o interrogando, Ana foi a sua casa para juntos usarem entorpecentes juntos no dia anterior ao cumprimento do mandado de busca pela polícia, e acabaram dormindo no local. Finalizou registrando que a ré ignorava a existência das drogas.

A corré Ana fez coro à narrativa de Iago, reforçando desconhecer a existência de mais narcóticos no imóvel.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, quando ao corréu Iago, a prova em juízo não destoou em momento algum de sua confissão, encontrando respaldo nas demais provas, em especial no depoimento do policial Maurílio, mostrando-se, portanto, elemento seguríssimo para condenação.

A propósito, em recente julgado:

"Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – (...) Consistentes relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Confissão judicial do réu – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Condenação mantida – (...) – Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

Destarte, sua condenação pelo crime de tráfico é de rigor, nada mais precisando se dizer.

A corré Elza, merece o mesmo destino condenatório.

Com efeito, a despeito de negar em todas as fases da persecução criminal a responsabilidade pelas drogas encontradas em sua posse (dentro de suas vestes íntimas), e em seu imóvel (interior da fralda no cesto de lixo do banheiro), dizendo que pertenciam ao seu esposo, certo é que o enredo não convence.

A uma, por ser absolutamente inverossímil. Afinal, é no mínimo contraditório que a ré, que se mostrou contrariada com o vício maldito de seu esposo, escondesse dentro de suas próprias roupas íntimas uma parte de suas drogas (duas porções de "maconha"), dispensando outra (treze porções de "cocaína"), sem contar as outras duas porções de "maconha" encontradas em seu quarto. Ora, se Elza pretendia confrontar seu esposo sobre as drogas, por discordar de tê-las guardadas em sua residência, por qual razão não as descartou imediatamente? Por que escondeu uma parte consigo, deixou outra à vista, e dispensou os pinos de "cocaína"? Não faz qualquer sentido!

A duas, porque a ré, olvidando-se do ônus probatório que sobre si recaía ao invocar tal tese, a teor do artigo 156, caput, do CPP, sequer demonstrou a condição de usuário de seu companheiro. Aliás, sequer o apresentou em juízo.

Portanto, a despeito da pequena quantidade de droga encontrada em sua posse/guarda, entendendo configurada a prática do crime de tráfico, já que somada à tal circunstância, tem-se ainda o fato de Elza já ser alvo de investigação anterior relacionada ao delito.

Lado outro, com relação à corré Ana Caroline (vulgo "Karol"), malgrado a alteração da versão que apresentou em sede policial em Juízo, entendendo que os elementos probatórios não autorizam sua condenação.

Decerto, muito embora as provas tenham apontado que acusada morava, ou ao menos frequentava com assiduidade o imóvel de Iago, o fato dos narcóticos terem sido achados durante a busca em local de difícil acesso (forro do telhado da residência), confere musculatura à sua versão de que deles não sabia.

Assim, revelando-se incerto que a acusada tivesse plena ciência da existência das drogas no local, impõe-se sua absolvição, com base no In Dubio Pro Reo.

Em reforço a tal conclusão, percebe-se que o próprio relatório de investigação que embasou a medida cautelar antecedente (autos em apenso nº 1500258-05.2021.8.26.0323), não indicou com precisão o agir sugestivo do tráfico da acusada, naquela ocasião referida como "Karol" (p. 04 naqueles autos).

Por fim, quanto ao crime de associação para o crime de tráfico de drogas, o destino de todos acusados é a absolvição.

Convém lembrar que não basta para subsumir a conduta em estudo ao tipo do artigo 35, da legislação de drogas, a presença de dois ou mais agentes, no caso Iago e Elza. É imprescindível que se revele o animus associativo, a estabilidade, permanência e organização do grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles.

No caso, em que pese confirmado o tráfico praticado por Iago e Elza, aqui reconhecido, à míngua da produção de provas a demonstrar tais requisitos, não há como condená-los pelo delito em questão.

Não se ignora as notícias policiais apresentadas nos autos em que deferidas as ordens judiciais de busca e apreensão nos domicílios dos réus; contudo, tais informações não relacionavam Iago e Elza, tal como se vê às fls. 04 daqueles autos; não restando comprovado o animus associativo entre eles, hierarquia, divisão de tarefas etc., portanto, insuficientes para a condenação do acusado pelo artigo 35, da Lei de drogas.

Confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação. (...) Associação - provas insuficientes. O crime em tela exige a vontade de dois ou mais agentes se associarem (animus associativo) e sua consumação se dá com a reunião estável e permanente, dispensando a prática do crime-fim. Não se demonstrou, contudo, mínima organização e hierarquia entre eles o que, após cotejar todos os elementos analíticos inseridos nos autos, não emerge com clareza meridiana o vínculo associativo. (...) Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão". (TJSP; Apelação Criminal 0002107-90.2016.8.26.0443; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017) (Ênfase minha).

Passo a dosagem das penas.

a) IAGO FELIPE EUFRAZIO EUGENIO:

O réu é primário e de bons antecedentes, conforme a certidão criminal de fls. 415/416.

Todavia, à luz da quantidade e diversidade do entorpecente encontrado em sua posse (36,99 gramas, de massa líquida, de "maconha"; 52,7 gramas, massa líquida, de cocaína, distribuídas em 155 pinos plásticos, do tipo eppendorf), entendo razoável a fixação da pena-base um pouco acima do piso legal, pois caso contrário, negar-se-ia vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatutura constitucional, por equiparar a conduta em tela à outras envolvendo apreensão de pequena quantidade de um único tipo de droga.

Portanto, diante dessas circunstâncias desfavoráveis, tenho por bem fixar a pena-base em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, ou seja, 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na etapa intermediária, reconheço a confissão espontânea do réu e a sua menoridade relativa, atenuando a pena em 1/3 (um terço) e, conseqüentemente, reconduzindo-a novamente ao patamar raso de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em respeito à jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não existem agravantes.

Na última etapa, não havendo outras circunstâncias alteradoras, torno definitiva a sanção tal como lançada na fase anterior.

Não é o caso de reconhecer a figura privilegiada do tipo, já que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, a despeito da condição de primário aos olhos da lei penal do acusado.

A uma, pois a testemunha policial confirmou que o réu foi visto em atitude típica do vil comércio durante as campanhas que ensejaram a ordem judicial de busca e apreensão domiciliar em seu endereço.

A duas, por ter sido apreendido no interior de sua residência, juntamente com as drogas lá encontradas, apetrecho utilizado no tráfico para venda no varejo em grande quantidade (pinos plásticos vazios, do tipo eppendorf), a reforçar a conclusão acima exarada.

A três, pelo fato de Iago sequer ter comprovado ao longo da instrução processual, o exercício de atividade lícita remunerada.

Neste sentido, trago à colação, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada não somente pela quantidade de drogas apreendidas - 17kg de maconha -, mas, também, em virtude da existência de outros elementos fáticos, notadamente a apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para a prática da traficância. (...) 2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 707.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (Sublinhei).

Aliás, como não existe prova direta dessa circunstância, dedicar-se à atividade

criminosa, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", é exatamente essas circunstâncias que comprovam a sua dedicação, conforme julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada". (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Assim, como determina a lei, tal redutora não se destina àquele que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, hipótese destes autos, mas sim, ao agente que age por um impulso esporádico, em caso isolado, incidindo, portanto, em situações específicas e excepcionais, quando evidenciado que o pequeno tráfico se tratou de singelo desvio na vida do acusado, não sendo o caso deste acusado.

Registre-se que tal entendimento encontra-se em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, já que a quantidade e diversidade das drogas apreendidas não foram os únicos elementos a ensejar a não aplicação do § 4º, do artigo em assunto, conforme fundamentação supra, não se podendo cogitar no odioso e proibido bis in idem.

A propósito, em recente julgado:

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença”. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (Sublinhado meu).

O regime inicial será o fechado, à luz das circunstâncias judiciais mencionadas, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão,

autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal, por serem incompatíveis tais benefícios com a natureza hedionda do crime, sendo certo que, ainda que assim não fosse, o montante aplicado da pena os inviabilizaria.

b) ELZA KARLA NOGUEIRA SILVA:

A ré é primária e de bons antecedentes. A quantidade da drogas igualmente não excede ao tipo penal. Note-se que não lhe são desfavoráveis as demais circunstâncias judiciais.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não existem atenuantes ou agravantes.

Na última etapa, por se tratar de ré primária de bons antecedentes, e ainda à míngua de provas a demonstrar sua dedicação às atividades criminosas, ou mesmo de que integre organização criminosa, concedo-lhe a redutora prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu máximo patamar, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), e finalizando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ausentes outra modificadoras.

Consolidada posição nos Tribunais Superiores acerca do afastamento do caráter hediondo do denominado tráfico privilegiado, fixo o regime inicial aberto à ré.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

a) condenar IAGO FELIPE EUFRAZIO EUGENIO, qualificado nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diária mínima;

b) condenar ELZA KARLA NOGUEIRA DA SILVA, qualificada nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, c.c § 4º, da Lei 11.343/06, a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima; e

c) absolver IAGO FELIPE EUFRAZIO EUGENIO, ELZA KARLA NOGUEIRA DA SILVA e ANA CAROLINE NOGUEIRA RODRIGUES MARÇAL, qualificada nos autos, das imputações restantes que lhes foram irrogadas na denúncia, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Preenchidos os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta à corré Elza por duas restritivas de direitos, já que o montante supera o prazo de um ano (artigo 44, § 2º, do Código Penal).

A primeira será a prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos, a ser realizado por meio de depositado em conta judicial, mediante a emissão da guia pertinente em cartório judicial.

Já a segunda será a prestação de serviço à comunidade. As tarefas serão prestadas gratuitamente, de acordo com a aptidão da ré, em entidade a ser designada, devendo ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, pelo seu

período.

Por outro lado, nego o apelo em liberdade em favor de Iago. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam sua prisão preventiva se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente.

Ademais, a pena relativamente alta que lhe foi imposta, assim como o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença conferem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, no entanto, expeça-se a guia de execução provisória.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Ana Caroline Nogueira Rodrigues Marçal.

Custas pelos vencidos, observado a gratuidade de justiça, que ora concedo ao acusado Iago.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário com o trânsito em julgado.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as

seguintes providências: a) Expeçam-se guias de execução definitivas; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA